

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS V

Inviolabilidade de sigilos

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Aqui há mais informações do que se imagina, por isso vamos analisar detalhadamente. Vamos examinar cada uma das informações presentes.

Primeiramente, perceba que no texto parece que alguns sigilos são invioláveis, mas há um que pode ser violado.

Até este ponto, o sigilo da correspondência e comunicação telegráfica, de dados, é inviolável, sem exceção. A partir daqui, no entanto, temos a comunicação telefônica, exceto em casos extremos. Parece que até agora não pode ser quebrado, mas daqui para frente pode. É o contrário, isto é, qualquer sigilo pode ser relativizado.

Lembre-se de que não há direito absoluto, já que todos podem ser relativizados. Assim, deve-se ler como tudo pode ser violado, dependendo das circunstâncias.

O mais difícil é exatamente o sigilo das comunicações telefônicas. Lembre-se de que a interceptação telefônica é diferente dos dados telefônicos. Por exemplo, em uma CPI, podemos ver que ela pode acessar dados bancários, fiscais e telefônicos, mas não pode acessar as comunicações telefônicas.

Quando se fala em comunicações telefônicas, é semelhante à inviolabilidade do domicílio, em que entra a cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, somente o poder judiciário pode determinar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Dados telefônicos incluem informações como extratos, quem ligou para você, para quem você ligou e a duração das chamadas. Esses dados podem ser relativizados.

Por exemplo, imagine que alguém esteja enviando uma correspondência para São Paulo, a qual possui vários micros selos de LSD, droga. Nesse caso, os correios podem abrir? E se for um pacote contendo cocaína ou maconha? Os correios podem abrir? Nesse contexto, isso indica que os correios podem abrir as correspondências em casos de fundada suspeita, mas não vão abrir todas sem razão fundamentada.

A mesma lógica se aplica ao diretor do presídio. O diretor do presídio, geralmente um membro da polícia, não é necessariamente uma autoridade judicial. Ele pode abrir as correspondências dos presos ou não? Apenas para recordar, alguns anos atrás, ocorreu no Brasil um evento chamado Salve Geral, no qual o líder do PCC, uma facção criminosa conhecida, enviou ordens para instigar o terror no estado de São Paulo, e isso foi feito por meio de uma carta proveniente do presídio. No presídio, as correspondências podem ser abertas.



A quebra do sigilo das comunicações telefônicas pode ocorrer por ordem judicial, nas situações determinadas pela lei, que é a Lei n. 9.296/1996. Entre 1988 e 1996, não era possível realizar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Isso ocorria porque não havia autorização legal. Mesmo com autorização judicial, durante esse período, não era permitido realizar a quebra dos sigilos.

Sem essa permissão legal, que envolve tanto a autorização judicial quanto a autorização legal, não era viável realizar a quebra dos sigilos. Aqui estamos lidando com uma situação de reserva legal qualificada. Isso significa que mesmo que houvesse previsão legal e autorização judicial, a escuta telefônica só poderia ser determinada pelo juiz dentro de um processo criminal, investigação criminal ou instrução processual penal.

O não pagamento de pensão alimentícia não configura crime, sendo um ilícito civil. Não seria possível determinar a quebra do sigilo nesse caso. Também não seria possível considerá-lo como improbidade administrativa, caso a ação seja de natureza civil.

Agora vamos explorar diversos desdobramentos sobre quem pode, quem não pode, e até onde se estende essa autorização, tudo isso será abordado a partir de agora.

Quebra de sigilos – Poder Judiciário

- Pode quebrar qualquer um dos sigilos, desde que o faça de forma fundamentada.
- Lembrar da inexistência de direito absoluto.
- A quebra é sempre medida excepcional.

A regra é a liberdade do cidadão, sendo a prisão uma exceção. A regra é a preservação da casa do indivíduo, enquanto a exceção é permitir a violação do domicílio. A regra é a preservação dos dados pessoais, sendo sua violação a exceção.

Então, o Judiciário tem o poder de quebrar qualquer sigilo, inclusive das comunicações telefônicas, mas sempre com fundamentação. Quando há dois direitos constitucionais em conflito, ocorre a ponderação de interesses no caso concreto, verificando-se se a medida é proporcional, adequada, necessária e razoável para proteger a coletividade naquele contexto específico.

Quebra de sigilos – CPI

Apesar de a CPI possuir poderes de investigação equiparados aos da autoridade judicial, esses poderes não se aplicam quando há a cláusula de reserva de jurisdição.

- CPI pode quebrar todos os sigilos, exceto o das comunicações telefônicas (interceptação, escuta, grampo).
- A quebra deve ser fundamentada e observando o **princípio da colegialidade**.

Uma das regras frequentemente abordadas em provas sobre CPI é o princípio da colegialidade. As decisões da CPI não podem ser tomadas exclusivamente pelo presidente ou pelo relator, mas sim pelo colegiado. Assim como o Poder Judiciário, a CPI também precisa fundamentar suas decisões. No entanto, essa fundamentação não necessita ser tão detalhada quanto a do Judiciário.

- CPIs ESTADUAIS/DISTRITAIS também podem quebrar, pois têm os mesmos poderes das autoridades judiciais.

CPIs estaduais, distritais e federais conferem aos deputados as mesmas imunidades e prerrogativas. Nas esferas estadual e distrital, assim como na federal, as imunidades parlamentares são uniformes. Portanto, as CPIs estaduais e distritais podem realizar quebras de sigilo nos mesmos casos em que as CPIs federais têm essa prerrogativa.

- CPIs MUNICIPAIS **não** podem quebrar sigilo, porque não há judiciário no município.

Porém, quando se trata do âmbito municipal, a situação é diferente. Embora exista a possibilidade de CPIs municipais, é importante ressaltar que tais comissões não possuem poderes de investigação das autoridades judiciais. Nos municípios, geralmente não há autoridades judiciais locais, uma vez que os fóruns pertencem ou a uma vara federal ou ao Tribunal de Justiça estadual.

Quando se trata de CPI, é importante destacar que ela pode buscar acesso aos dados contidos em uma interceptação deferida pelo Judiciário. Se houver autorização judicial para o compartilhamento de provas, não há impedimento para tal ação por parte da CPI.

Quebra de sigilos – Ministério Público

- Prevalece a orientação de que o Ministério Público não pode quebrar sigilos, devendo requerer a providência ao Poder Judiciário.

ATENÇÃO

O MP poderia ter acesso a contas pertencentes à Prefeitura, independentemente de autorização judicial, até porque nesse caso o poder público seria o titular da conta.

No contexto da inviolabilidade de sigilos, é importante considerar a preservação da intimidade e privacidade das pessoas. Entretanto, no caso de uma conta bancária registrada em nome de um ente público, como uma prefeitura municipal, não há problema em o Ministério Público requisitar as informações, uma vez que o ente público não possui essa mesma expectativa de privacidade.



10m

Mas, o Ministério Público não pode solicitar diretamente a quebra do sigilo bancário de pessoas físicas, jurídicas ou empresas comuns. Essa questão já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, os quais validaram tal procedimento apenas quando se trata de contas em nome de entes públicos.

- *Big techs* e preservação de dados telemáticos (contas da internet) sem autorização judicial.

Vamos abordar agora algumas questões pertinentes. Primeira situação: preservação de dados telemáticos, como contas na internet, com solicitação direta do Ministério Público às grandes empresas de tecnologia.

O Ministério Público solicitou o congelamento dos dados ao Google e à Apple, abrangendo dispositivos Android e iOS. As empresas receberam o pedido e congelaram os dados.

Por que congelar os dados? Vamos entender com um exemplo prático. Às vezes, alguém faz ofensas online e depois tenta apagá-las ao perceber as consequências. Mas ao solicitar o congelamento dos dados, mesmo que apague a postagem, os dados permanecem criptografados e preservados, aguardando autorização judicial para acesso. Portanto, a falsa percepção de que a internet é uma terra sem lei não procede. Solicitando a preservação dos dados, é possível responsabilizar quem cometeu irregularidades, mesmo que tente apagar as evidências.

O Supremo Tribunal Federal julgou casos nos quais tanto a Google quanto a Apple estavam recebendo pedidos do Ministério Público sem a devida autorização judicial. O Ministério Público estava investigando questões relacionadas ao Detran nesse julgamento. Solicitou aos provedores da Apple e da Google a preservação dos dados e dos e-mails, que são identificadores do aparelho.

O tribunal recolheu todas as provas e realizou o julgamento. No entanto, ao chegar ao Supremo, este destacou que o congelamento e a perda da disponibilidade dos dados, por não terem se baseado em uma decisão judicial, configuraram desrespeito à Constituição Federal e ao Marco Civil da Internet. Ambos os dispositivos legais foram violados, pois é necessária autorização judicial para tal medida, não cabendo ao Ministério Público decidir nesse contexto.

Acesso a dados cadastrais – MP e POLÍCIA

Em 2019, foi introduzido o pacote anticrime, amplamente conhecido. Este pacote gerou diversos desdobramentos, incluindo uma disputa entre Ministério Público e autoridades policiais. A questão central era saber se o Ministério Público era o único autorizado a fazer acordos de colaboração premiada, ou se a polícia também poderia fazê-lo.



15m

O Supremo Tribunal decidiu que a polícia também tinha essa prerrogativa, uma decisão que desagradou o Ministério Público, mas foi bem recebida pela polícia. Às vezes, contrariar a polícia não é fácil, especialmente quando se trata do poder de investigação.

Entretanto, esta decisão levanta a possibilidade de união entre Ministério Público e polícia. Antes do pacote anticrime, uma alteração no Código de Processo Penal buscava dar mais agilidade às investigações policiais de certos crimes, permitindo tanto ao Ministério Público quanto à polícia acesso a dados para esse propósito.

- Arts. 13-A e 13-B do CPP;
- Empresas de telefonia e fornecimento de dados cadastrais;

Os arts. 13A e 13B do Código de Processo Penal representam uma técnica legislativa de expansão do texto original. Esta prática, também observada na Constituição, consiste em adicionar letras ao número do artigo, como uma forma de evitar a renumeração completa dos artigos. Em vez de criar um novo artigo como o 14, por exemplo, é adicionada uma letra ao número existente, como 13A e 13B.

Essa abordagem é comum em legislações quando ocorrem alterações nos textos originais. Portanto, a presença de 13A e 13B indica que esses não são partes do texto original do Código de Processo Penal, que remonta a 1941, mas sim adições posteriores, como a de 2016.

Apesar de datar de 2016, o julgamento que será discutido é de 2024, evidenciando o tempo decorrido para o Supremo Tribunal entender a validade dos artigos 13A e 13B em determinados casos.

Esses artigos autorizam as empresas de telefonia a fornecerem dados cadastrais diretamente às autoridades de investigação, como o Ministério Público e a polícia, sem a necessidade de autorização judicial.

Essa medida visa agilizar a investigação de crimes específicos, como casos de cárcere privado ou sequestro de crianças, proporcionando mais eficiência na apuração. É importante ressaltar que essa autorização não se aplica a todos os tipos de crimes de forma genérica, mas sim a situações específicas que demandam uma resposta rápida por parte das autoridades.

- Crimes abrangidos: **tráfico de pessoas**, cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de crianças ao exterior.

Ao utilizar aplicativos como Waze ou Google Maps em seu telefone, sua localização é determinada por meio do cruzamento de sinais, utilizando estações rádio base (ERBs). Isso permite que a polícia acompanhe em tempo real o deslocamento tanto da vítima quanto do agressor em casos de sequestro ou fuga, desde que haja autorização judicial.



20m

Contudo, há uma distinção importante quanto ao compartilhamento dos dados cadastrais: se a análise do juiz for concluída em até 12 horas, o compartilhamento é feito com autorização; caso contrário, as autoridades solicitam diretamente às empresas de telefonia.

Em nenhum cenário, Ministério Público e Polícia têm acesso às conversas, pois isso configuraria quebra do sigilo das comunicações telefônicas, o que requer aprovação do Poder Judiciário, respeitando a cláusula de reserva de jurisdição. O objetivo é rastrear a localização em tempo real, não obter o conteúdo das conversas.



Quebra de sigilos – Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas possui os chamados Poderes Implícitos, que se referem à teoria dos Poderes Implícitos da doutrina norte-americana, conhecida como *Implicit Powers*. Essa teoria estabelece que quem tem autoridade para uma determinada função também possui os meios necessários para executá-la.

Por exemplo, se a Constituição atribui ao Ministério Público a função de apresentar denúncias em ações penais públicas, o Ministério Público também tem o poder de investigar e reunir evidências para sustentar suas acusações.

Da mesma forma, o Tribunal de Contas, cuja missão é fiscalizar o dinheiro público, possui esses poderes implícitos para cumprir sua função. No entanto, é importante ressaltar que entre esses poderes implícitos não está incluída a capacidade de quebrar sigilo.

- Embora possua os chamados poderes implícitos, os TCs **não** podem quebrar sigilos, devendo requerer a providência ao Poder Judiciário.

O caso que chegou ao Supremo envolve o BNDES emprestando uma grande quantia de dinheiro para a empresa J&F, a holding do grupo JBS Freeboy. Este empréstimo para uma das maiores produtoras de carne do mundo é uma prática comum para estimular atividades econômicas.

Entretanto, o Tribunal de Contas queria fiscalizar o contrato devido ao grande montante de dinheiro público envolvido. O BNDES alegou que, por ser um banco, estava protegido pelo sigilo bancário. O Tribunal de Contas, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que determinou que o sigilo fosse quebrado para permitir a fiscalização.

No entanto, o BNDES argumentou que não era necessário quebrar o sigilo, mas sim acessar as informações contidas no contrato, visto que envolvia dinheiro público. Com isso, o Tribunal de Contas pôde realizar a fiscalização sem que o acesso fosse rotulado como quebra de sigilo.

O Supremo Tribunal Federal entende que o Tribunal de Contas da União tem autoridade para realizar duas ações específicas: desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa e decretar a indisponibilidade cautelar de bens. Contudo, não pode quebrar sigilo, mas pode acessar informações.

Ambas as ações decretar a indisponibilidade de bens são permitidas de forma cautelar. A desconsideração da personalidade jurídica também é válida. Já vimos que os Tribunais de Contas podem se envolver em questões políticas.

Agora, vamos abordar o envolvimento da Receita Federal.

ATENÇÃO



Caso envolvendo empréstimo do BNDES ao grupo JBS/FRIBOI – possibilidade de requisição de informações pelo TCU.

Quebra de sigilos – Receita Federal

- Transferência de sigilos e a LC 105/2001.

Existe a Lei Complementar 105 de 2001, que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. Um banco, considerado uma instituição financeira, identificou uma movimentação suspeita em uma conta, classificada como atípica.

Em seguida, o banco informou à Unidade de Inteligência Fiscal, conhecida como COAF. O COAF, por sua vez, repassou essa informação para a Receita Federal, que, por sua vez, encaminhou para o Ministério Público.

Não há envolvimento do Judiciário nesse processo. Esse procedimento não é considerado quebra de sigilo, mas sim transferência de sigilo, pois os dados continuam sendo mantidos em sigilo ao serem compartilhados entre os órgãos de forma sigilosa. Isso não requer uma ordem judicial.

Esse cenário está relacionado ao caso Queiroz, que envolveu o ex-presidente. Esse processo de transferência de informações suspeitas já foi validado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos.

Sigilo das comunicações telefônicas

- Prazo: Lei x jurisprudência – renovações sucessivas?

A Lei n. 9.296 /1996, que trata da interceptação, estabelece um prazo inicial de 15 dias, prorrogável por igual período. Embora mencione 15 mais 15 dias, a jurisprudência permite renovações sucessivas e sem limite de tempo, desde que haja fundamentação demonstrando a necessidade no caso específico.

A justificativa precisa ser detalhada, não bastando apenas marcar um X em um relatório. As renovações são ilimitadas, desde que devidamente fundamentadas. Além disso, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já proferiram decisões permitindo que o juiz estabeleça prazos diretos de 30 dias, sem a necessidade de intervalos de 15 em 15 dias. Isso ocorre porque, se a lei permite 15 mais 15 dias, também permite 30 mais 30, e assim por diante.

- Incidência do fenômeno da serendipidade;
- Degração dos diálogos: integral x parcial.

Durante as interceptações, a defesa terá acesso ao que foi interceptado, mas não imediatamente. Isso é feito para evitar interferências durante as interceptações. Primeiro, a prova é produzida e somente depois é disponibilizada para a defesa.

Não é necessário transcrever integralmente as gravações; uma transcrição parcial é suficiente, desde que a mídia completa seja entregue à defesa. A defesa deve ter acesso a todas as informações, mesmo que a polícia transcreva apenas o que considera relevante.

Esse processo pode revelar evidências de crimes adicionais, conhecido como serendipidade, ou encontro fortuito.

Se novos suspeitos com jurisdição especial surgirem durante a investigação, o juiz deve encaminhar o caso para o tribunal competente decidir sobre o prosseguimento do processo. Se a autoridade incompetente continuar produzindo provas após a descoberta de uma autoridade com jurisdição especial, essas provas se tornarão nulas.



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
